

A토지에 관하여 乙 앞으로 2019.2.5. 매매를 원인으로 한 소유권이전등기가 마쳐져 있다(현재 등기부상 소유자가 乙로 되어 있다). 甲은 乙과 丙이 서로 공모하여 등기관 관련 서류를 위조하여 법률상 원인 없이 위 등기를 마쳤다고 주장하면서, 乙을 상대로 소유권이전등기 말소등기 청구의 소를 제기하였다(아래 각 설문은 상호 독립적인 것임).

문1. 甲의 주소지는 서울이고, 乙의 주소지는 부산이다. 만일 甲이 청주지방법원에 소를 제기한 경우, 이 법원에 관할권이 생기는 경우는 어떤 경우인지에 관하여 모두 설명하라(20점).

문2. 만약 甲이 乙과 丙을 상대로 위 말소등기 청구의 소를 제기하였다면, 법원은 丙에 대하여 어떤 판결을 선고해야 하는가(20점)?

문3. 乙은 소 제기 이전에 이미 사망하였고, 그 상속인으로 丁이 있는데, 甲은 소송계속 중 이러한 사실을 알게 되었다. 이 경우 甲이 丁을 상대로 소송을 진행하기 위해서 甲은 어떠한 조치를 취해야 하는가(10점)?

문4. 戊는 2019.1.5. 甲으로부터 A토지를 증여받았다고 주장하면서, 甲을 대위하여 乙을 상대로 위 말소등기 청구의 소를 제기하였다. 이 때 법원이 戊와 甲 사이의 2019.1.5.자 증여사실을 인정할 수 없다는 심증이 든 경우, 법원은 어떠한 판결을 선고하여야 하는가(20점)?

문5. 만약 위 4.항의 戊가,

(1) 그 대표자인 X 등 10인으로 구성된 법인이 아닌 사단이라면, 戊 또는 그 구성원은 어떠한 방법으로 위 말소등기 청구의 소를 제기하여야 하는가(10점)?

(2) 그 대표자인 X 등 10인으로 구성된 민법상 조합이라면, 戊 또는 그 구성원은 어떠한 방법으로 위 말소등기 청구의 소를 제기하여야 하는가(20점)?

<채점기준>

문1.

(1) 보통재판적과 특별재판적

토지관할의 발생 원인이 되는 인적, 물적 관련지점으로서의 재판적에는 보통재판적(부산)과 특별재판적이 있다. 만약 A토지가 청주지방법원의 관할 지역에 위치하고 위 토지의 관할 등기소가 청주에 있는 경우라면 민소법 제21조에 의해 청주법원에 관할권이 생긴다.

(2) 합의관할 - 만약 甲과 乙이 청주법원을 관할법원으로 하는 관할에 관한 합의를 하였다면 청주법원에 관할권이 생긴다.

(3) 변론관할 - 청주법원에 토지관할권이나 관할에 관한 합의에 기한 관할권이 없었으나 甲이 청주법원에 소를 제기하였고 피고 乙이 변론기일이나 변론준비기일에 출석하여 관할위반의 항변을 하지 않은 채 본안에 관하여 변론하면 민소법 제30조에 의하여 청주법원에 관할권이 생긴다.

문2.

(1) 이행의 소에 있어서의 당사자적격

등기부상 명의자가 아닌 丙에게 당사자적격이 인정되는가?

(2) 원칙 - 이행청구권자임을 주장하는 자에게 원고적격이, 그에 의해 이행의무자로 주장된 자에게 피고적격이 인정됨. 즉 원고의 주장 자체에 의해 당사자적격의 유무가 판가름되는 것이지 실제로 원고 또는 피고가 이행청구권자이거나 이행의무자일 것을 요하는 것은 아님. 이러한 이행청구권이나 이행의무의 존부는 본안에서 판단되어야 할 사항임.

(3) 예외(판례) - 등기관련소송에 있어서 등기명의인이나 그 포괄승계인(등기의무자) 이외의 자를 상대방으로 하는 말소등기청구는 당사자적격(피고적격) 없는 자를 상대로 한 부적법한 소라고 함.

(4) 결론 - (2)에 따른 결론을 도출할 경우 가점 부여.

문3.

(1) 당사자확정의 기준과 당사자표시의 정정

(2) 피고의 경정신청(민소법 제260조)

문4.

(1) 채권자대위소송의 성질(통설, 판례)

제3자소송담당(법정소송담당)- 채권자의 채무자에 대한 채권의 보전(원칙적으로는 채무자의 책임재산보전)을 위하여 채권자에게 채무자를 대신하여 그의 권리에 관한 소송수행권을 법률(민법)이 부여한 것임.

(2) 대위권 행사의 요건(대위소송의 요건)

당사자적격에 관한 소송요건으로 ① 피보전권리의 존재, ② 채무자의 권리불행사, ③ 채권보전의 필요성이 모두 인정되어야 한다.

(3) 사안의 경우 위 ①요건이 결여되어 있는 경우이므로 법원은 소송요건의 불비(당사자적격의 흠결)를 이유로 소를 부적법 각하하는 판결을 선고해야 한다.

문5의 (1)

(1) 戊는 법인 아닌 사단으로서 그 대표자 X가 있으므로 민소법 제52조에 의해 戊의 이름으로 소를 제기할 수 있다. 다만, 사안의 경우 위 소송은 총유재산에 관한 소송이므로 사원총회의 결의를 거쳐서 제기하여야 한다.

(2) 민법상 총유재산에 관한 관리처분권은 법원 아닌 사단의 구성원 전원에게 공동으로 귀속되므로 사안의 경우 戊의 구성원인 X 등 10인 전원이 당사자가 되어 고유필수적 공동소송의 형태로 소를 제기하여야 한다.

문5의 (2)

(1) 민법상 조합에 당사자능력이 인정되는가?

긍정설, 부정설(판례)

(2) 긍정설을 취할 경우 戊는 그 대표자 X가 戊의 이름으로 소를 제기할 수 있다.

(3) 부정설을 취할 경우

1) 합유인 조합재산에 관한 소송은 보전행위에 관한 소송이 아닌 한 조합원 전원이 당사자가 되어 고유필수적공동소송의 형태로 소송을 진행하여야 한다. 이에 의할 경우 소송이 복잡하게 되고 지연될 문제가 있으므로 이를 간명화하기 위한 몇 가지 방법이 있다.

2) 조합원 중에서 선정당사자를 선출하여 그로 하여금 소송을 수행하게 하는 방법(민소법53조), 조합원이 업무집행조합원에게 소송수행권을 수여(임의적 소송신탁)하여 그로 하여금 소송을 수행하게 하는 방법, 업무집행조합원을 법률상의 소송대리인으로 보고 그로 하여금 소송을 수행하게 하는 방법이 그것이다.

(4) 결론